

[문제-1] (30점)

甲은 전기자동차에 관한 신규한 디자인 A를 창작하여 2021. 10. 1. 이를 기자회견을 통하여 공개한 후 2021. 12. 1. 제1국에서 디자인등록출원하였다. 그 후 甲은 2021. 12. 5. 전기자동차에 관한 TV 프로그램 방송에서 자신의 디자인 A를 공개하였다. 甲은 제1국 출원에 기초하여 2022. 5. 1. 조약 우선권을 주장하면서 전기자동차에 관한 디자인 A를 국내에서 디자인등록출원하였는데, 제1국의 출원은 무효로 되었다. 그 후 甲은 2022. 6. 1. 자신의 전기자동차 디자인을 좀 더 실효적으로 보호하기 위하여 A와 유사한 디자인 A'를 창작하여 디자인등록출원하였다. 다음 물음에 답하시오.

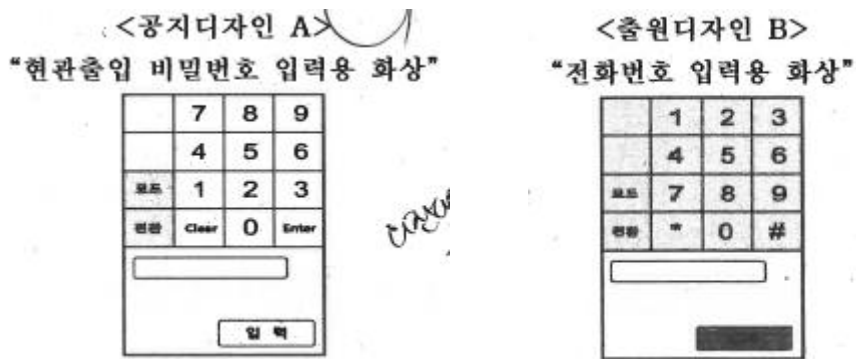
- (1) 甲의 디자인등록출원 A는 등록받을 수 있는지 설명하시오. (10점)(박규태4회실전GS #2와 유사)
- (2) 甲의 디자인등록출원 A'는 등록받을 수 있는지 설명하시오. (8점)(박규태8회실전GS #2와 유사)
- (3) 甲이 디자인 A에 대한 자신의 공개행위들에 대하여 신규성 상실 예외주장을 하면서 디자인등록출원을 한다면 등록받을 수 있는지 설명하시오. (12점)(박규태7회실전GS #1-2와 유사)

[문제-2] (20점)

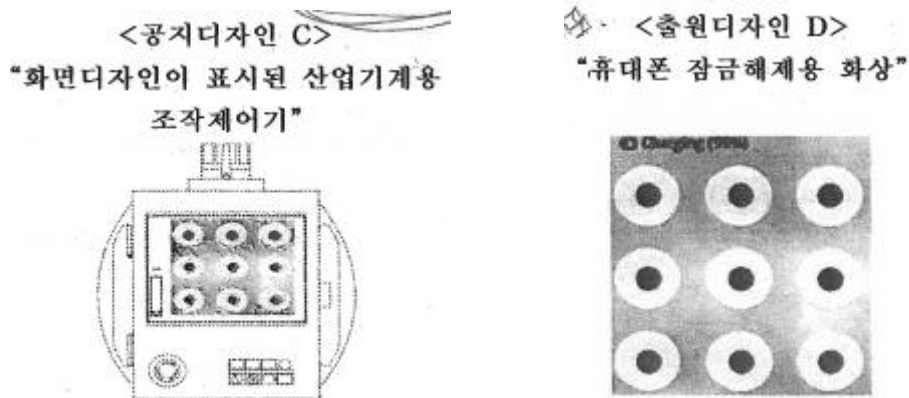
화상디자인과 관련한 다음 물음에 답하시오. ((1)은 박규태 기초 GS 문제-1 설문1과 유사)

(1) 공간 등에 투영된 가상 키보드를 조작하기 위한 목적으로 “가상 키보드용 화상”을 디자인 하였다. 이 화상디자인이 디자인보호법령상 디자인으로 성립될 수 있는지 설명하시오. (6점)

(2) 공지디자인 A는 “현관출입 비밀번호 입력용 화상”에 관한 디자인이며, 출원디자인 B는 “전화번호 입력용 화상”에 관한 디자인이다. 디자인 A와 Q의 유사여부를 설명하시오. (7점)

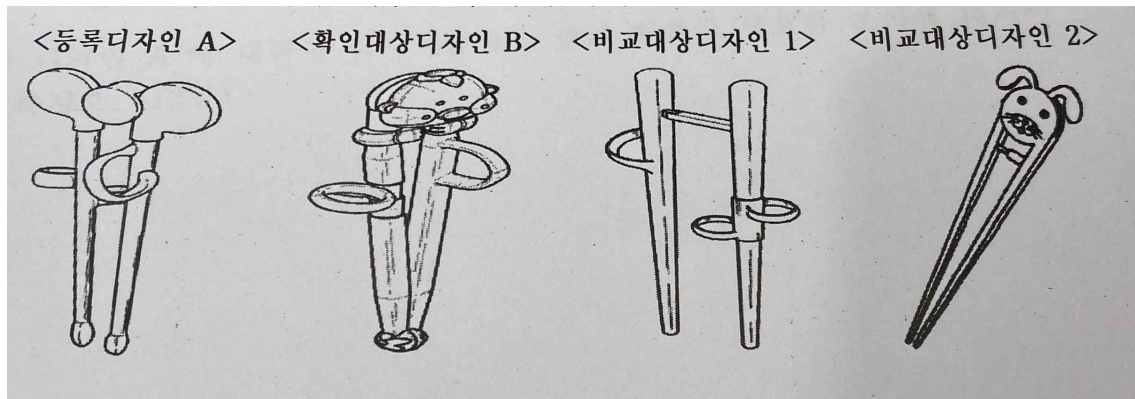


(3) 甲의 공지디자인 C는 “화면디자인이 표시된 산업기계용 조작제어기”로 “물품의 부분에 표현된 화면디자인”이다. 乙의 출원디자인 D는 “휴대폰 잠금해제용 화상”으로 “화상디자인”에 해당한다. 그런데 디자인 C가 출원된 다음 디자인 D가 출원되었고, 이후 선출원된 디자인 C가 디자인 공보에 게재되었다. 이때 화상디자인 D에 대한 디자인보호법상 확대된 선출원에 관한 규정의 적용여부를 설명하시오. (7점) (박규태 실전GS 3회 문제 4(2)와 동일)



[문제-3] (30점)

甲의 등록디자인 A와 乙의 확인대상디자인 B는 “어린이 젓가락 사용법 교육용 젓가락의 형상과 모양에 관한 디자인”이다. 확인대상디자인 B의 “손가락 삽입부”는 등록디자인 A의 “손가락 삽입부”와 유사한 한편, 확인대상디자인 B의 “캡 부분”은 유명 캐릭터를 부착하고, “젓가락 몸체 하단 부분”은 음식을 잘 집게 하기 위하여 손가락 모양의 볼록한 꽃문양으로 이루어졌다. 비교대상디자인 1, 2는 모두 이 사건 등록디자인 출원 전에 공지된 “젓가락의 형상과 모양에 관한 디자인”이다. 다음 물음에 답하시오.



(1) 디자인 성립요건으로서 “심미성”에 대하여 설명하시오. (7점)

(2) 동일한 물품에 대해 대법원 판례를 중심으로 아래의 기준을 각각 설명하시오. (15점)

1) 디자인 유사 여부 판단의 관찰방법에 있어서의 구체적 판단기준 (7점)

2) 디자인의 일부에 공지부분이 있는 경우와 디자인 일부에 물품의 기능에 관련된 형태가 있는 경우, 유사 여부의 구체적 판단기준 (8점)(디자인 실전GS 7회 문제-1 설문1-1과 유사)

(3) 甲이 乙에 대하여 적극적 권리범위확인심판을 제기하였을 경우, 물음 (2)에 따른 결과를 설명하시오. (8점)

[문제-4] (20점)

甲은 스마트워치에 관하여 신규한 디자인 A를 창작하여 2021. 6. 1. 디자인등록출원하였으나 거절 결정되어 확정되었다. 그 후 乙은 甲의 디자인과 동일한 디자인 A와 이와 유사한 디자인 A'을 창작한 후, 이들 각각에 대하여 2022. 7. 1. 디자인등록출원하였다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 乙의 디자인 A는 등록받을 수 있는지 여부에 대하여 설명하시오. (단, 이때 디자인 A'은 고려하지 않음) (8점)

(2) 乙이 디자인 A'에 대하여 디자인등록을 받기 위하여 필요한 조치에 대하여 설명하시오. (12점) (박규태 기초GS 6회 문제-2 설문1과 유사)

2022 기출문제 총평

먼저, 이공계 최고 난이도 시험인 2022 변리사 2차 시험의 마지막 시험까지 포기하지 않고 끝까지 고민하고 고생하신 모든 수험자분들에게 경의를 표합니다.

P/F 제도의 취지에 맞게, 전체적인 난이도는 높지 않다고 판단됩니다. 특히, 심미성을 제외한 대부분의 논점은 A급 위주로 출제되었습니다. 다만, 기출문제의 특성상 논점 자체가 명확하지 않은 사례형 문제에 대해 어려움을 느끼는 수험자분들, 또는 뽕뽕이 젓가락 판례에 대한 결론/이유를 제대로 이해하지 못한 수험자분들에게는 체감난이도가 높아질 수 있다고 판단됩니다. 다만, 난이도/배점은 상대적이고, 논점/답에 대해 정확히 파악하셨다면 P/F에 대해 크게 걱정하지 않으셔도 된다고 감히 말씀드립니다.

혹시, 논점/답을 4개 이상 틀린 수험자분들께서는, 제 단권화 교재인 QN 디자인보호법에 기재된 A급 논점 위주로 학습하시고, 이번 2022 기출강의를 포함한 기출문제를 더욱 연습하신다면 좀더 향상되실거라고 생각합니다.

1. 문제 유형 - (문제1-4) 사례/심사기준/판례/사례
2. 문제 난이도(ABC급) - (문제1-4) B/C/A/B
3. 문제 최대 배점 - 12점 (문제1-3, 문제4-2)
4. 문제 주논점
 - (1) 문제 1 - 조약우선권주장, 선출원, 신규성, **신규성상실예외주장**
 - (2) 문제 2 - 화상디자인의 성립요건, 유사, 확대된선출원주의
 - (3) 문제 3 - **심미성**, 유사
 - (4) 문제 4 - 선출원, 관련디자인, 1디자인

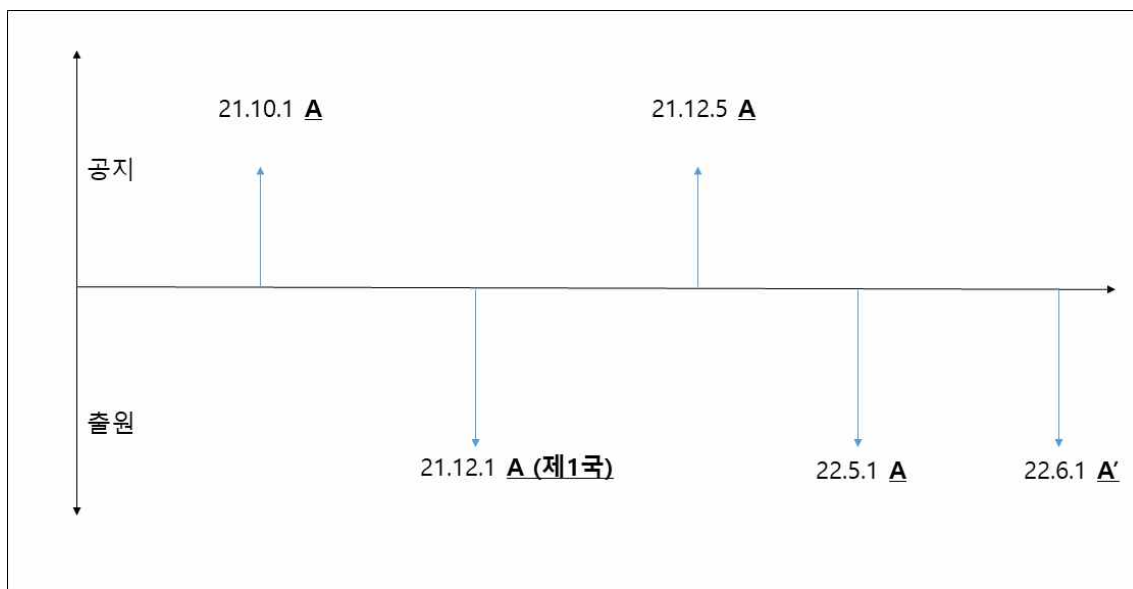
[문제-1] (30점)

甲은 전기자동차(물품, 12류, 심사등록출원)에 관한 신규한 디자인 A를 창작(36조)하여 (공지 1)2021. 10. 1. 이를 기자회견을 통하여 공개한 후 2021. 12. 1. 제1국(조약우선권주장, 6개월)에서 디자인등록출원하였다. 그 후 甲은 (공지2)2021. 12. 5. 전기자동차에 관한 TV 프로그램 방송에서 자신의 디자인 A를 공개하였다. 甲은 제1국 출원에 기초하여 (출원1-선출원)2022. 5. 1. 조약우선권을 주장하면서 (물품동일)전기자동차에 관한 (디자인동일)디자인 A를 국내에서 디자인등록출원하였는데, 제1국의 출원은 무효로 되었다(파리조약4A, 정규성). 그 후 甲은 (출원2-후출원)2022. 6. 1. 자신의 전기자동차 디자인을 좀 더 실효적으로 보호하기 위하여 A와 (동일인간 선출원주의, 관련디자인)유사한 디자인 A'를 창작하여 디자인등록출원을 하였다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 甲의 디자인등록출원 A는 등록받을 수 있는지 설명하시오. (10점) (주논점은 51조, 주-객시-절 중 정규성 및 나머지 요건 포섭, 효과, 신규성 위반, 36조는 간단히)

(2) 甲의 디자인등록출원 A'는 등록받을 수 있는지 설명하시오. (8점) (주논점은 46조/35조, 관련디자인등록출원을 하지 않은 경우의 후출원 요건 포섭, 관련디자인등록출원을 한 경우의 요건 포섭, 효과, 신규성 위반, 51조/36조는 간단히)

(3) 甲이 디자인 A에 대한 자신의 공개행위들에 대하여 신규성 상실 예외주장을 하면서 디자인등록출원을 한다면 등록받을 수 있는지 설명하시오. (12점) (주논점은 36조, 36조의 요건(주객시절) 포섭, 복수의 공지행위에서 최선 공지만 주장한 경우 동일성 포섭, 출원1 및 출원2 따로 포섭, 출원2는 (설문2와 중복되더라도) 35조 출원/보정 및 51조 출원/보정을 언급)



I. 설문 1

1. 조약우선권주장 적법 여부

(1) 法 51조 취지, 의의 및 요건

(2) 기초출원이 무효된 경우 적법 여부(파리조약4A(정규성))

정규출원은 출원의 소멸여부에도 불구하고 출원번호 및 연월일이 부여된 출원을 의미

(3) 효과 - 33조, 46조상 소급효

2. 신규성 위반 여부

(1) 法33조1항각호 취지, 의의 및 요건

(2) 취급 - 거절이유(法62,55)

3. 설문1의 해결

(1) 甲 A의 조약우선권주장이 적법한지 - 적극

1) 출원인은 甲 동일

2) 최선출원, 출원 무효가 되어도 정규성 있음, 전기자동차/A 동일

3) 2021.12.1.~6개월 내인 2022.5.1., 취지/증명서류 제출시 적법

(2) 甲 A의 등록가능성 - 소극

1) 효과 - 2021.12.1. 기준 판단 / 전제 - 심사등록대상물품

2) 甲 A의 신규성 위반 여부 - 적극 (21.10.1, 비밀유지의무없는 기자에게 공지, A-A 동일)

3) 거절이유상 36조 비주장시 등록불가

II. 설문 2

1. 동일인간 선출원주의 위반 여부

(1) 法46조제1항 취지, 의의 및 요건

(2) 동일인간 적용여부(法35조제1항과의 관계)

(3) 취급 - 신고요구, 거절이유(法62,55)

2. 관련디자인등록출원

(1) 法35조1항-3항 취지, 의의 및 요건

(2) 효과

3. 甲 A'의 등록가능성 - 관련디자인등록출원을 하지 않은 경우

(1) 法46조1항위반인지 포섭 - (51조)2021.12.1./2022.6.1., 甲 A -A'

(2) 거절이유상 등록불가

4. 甲 A'의 등록가능성 - 관련디자인등록출원을 한 경우

(1) 法35조요건 포섭 - 2021.5.1.~1년./2022.6.1., 甲 A-A', 甲-A 자기공지

(2) (法51조를 주장했더라도) 法.33조1항각호 위반의 거절이유상 36조 비주장시 등록불가

Ⅲ. 설문 3

1. 신규성/선출원주의 위반이 거절이유인지 간단히

2. 신규성 상실 예외 주장의 적법성

(1) 취지 판례(2014후1341 판결, 간이형스프링쿨러, 창작자보호/산업발전/제3자권익보호)

(2) 의의 및 요건

(3) '디자인등록받을 수 있는 권리를 가진 자' - 法3조제1항

3. 복수의 공지행위에 대하여 최선 공지행위에 대한 36조 주장시 효력범위

(1) 판례(2014후1341 판결, 간이형스프링쿨러, 제3자권익보호상 동일, 유사X)

(2) 검토

4. 설문의 해결 - 출원 1의 경우

(1) 51조상 판단시점 - 2021.12.1.

(2) 36조 주장의 적법성 - 적극

1) 甲 A 창작

2) 21.10.1~1년/21.12.1 출원, 취지/증명서류 제출시 신규성 극복, 등록가능

5. 설문의 해결 - 출원 2의 경우

(1) 51조 주장한 경우 - 출원 1과 동일

(2) 51조 주장하지 않은 경우 36조 주장의 적법성 - 적극

1) 甲 A 창작

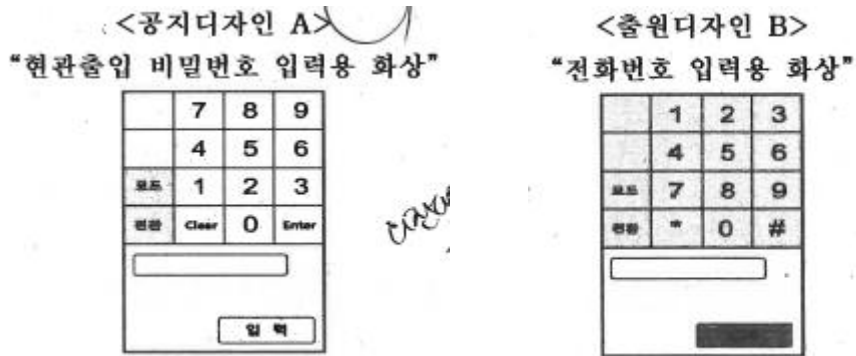
2) (공지1) 21.10.1~1년/21.6.1 출원, 공지1만 주장해도 (공지2) 21.12.5 공지한 A/전기자동차와 동일하므로 효과 미침

(3) 35조 출원/48조2항 보정시 신규성/선출원주의 극복, 등록가능

[문제-2] (20점)

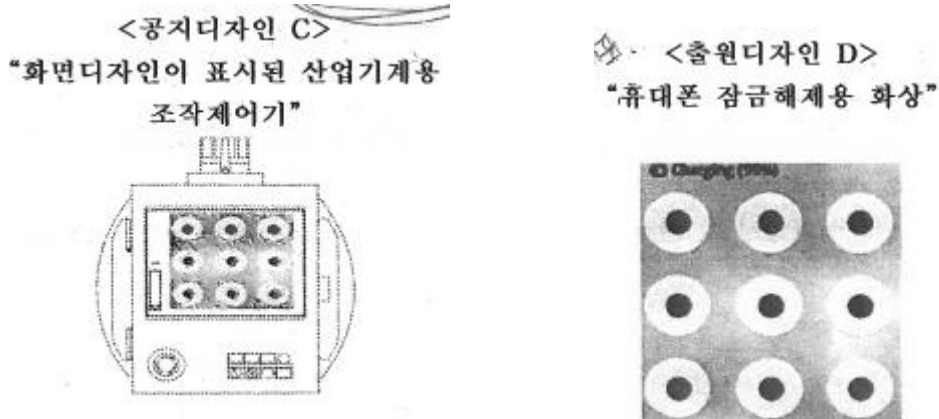
화상디자인(14류, 심사등록)과 관련한 다음 물음에 답하시오.

- (1) 공간 등에 투영된 가상 키보드를 조작하기 위한 목적으로 “가상 키보드용 화상”을 디자인 하였다. 이 화상디자인이 디자인보호법령상 디자인으로 성립될 수 있는지 설명하시오. (6점)
(화면디자인으로는 2조1호성립X(물품성-유체성X), 화면디자인은 2조2의2조작용화상임을 포섭)
- (2) 공지디자인 A는 “현관출입 비밀번호 입력용 화상”에 관한 디자인이며, 출원디자인 B는 “전화번호 입력용 화상”에 관한 디자인이다. 디자인 A와 B의 유사여부를 설명하시오. (7점)



(유사 일반, 주된 논점은 용도 유사(수치를 입력), 부수적 논점은 공통점(배치)/차이점(숫자문자)/숫자문자는비요부차이)

- (3) 甲의 공지디자인 C는 “화면디자인이 표시된 산업기계용 조작제어기”로 “물품의 부분에 표현된 화면디자인”이다. 乙의 출원디자인 D는 “휴대폰 잠금해제용 화상”으로 “화상디자인”에 해당한다. 그런데 디자인 C가 출원된 다음 디자인 D가 출원되었고, 이후 선출원된 디자인 C가 디자인 공보에 게재되었다. 이때 화상디자인 D에 대한 디자인보호법상 확대된 선출원에 관한 규정의 적용여부를 설명하시오. (7점) **(33조3항, 요건포섭, 주된 논점은 부분디자인의 일부/(조작용 기능)용도 비유사/혼용가능성 없음)**



I. 설문 1

1. 디자인보호법상 디자인의 유형 (21.11.18 시행 개정법)

法2조1호의 물품의 형태, 2조2의 글자체, 2조의2의 화상

2. 가상키보드용 화상이 2조1호의 디자인인지 - 소극

: 화상이 물품이 아닌 공간에 투영되어, 물품성 흠결

3. 가상키보드용 화상이 2조2호의2의 디자인인지 - 적극

: 공간 등에 투영되어 표현되고, 기기인 가상키보드 조작에 이용되는 도형/기호인 화상임.

II. 설문 2

1. 양 디자인의 유사 - 취지, 의의 및 관련 법(法33,46,92)

2. 화상디자인간 유사의 전제 - 화상디자인의 용도/기능의 유사 또는 혼용가능성

3. 문자/숫자의 유사판단시 중요도 - 낮게 평가

4. 설문 2의 해결 - A/B 유사

(1) 디자인 유사 - 적극

1) 공통점 - 사각형의 배치가 동일

2) 차이점 및 평가 - 숫자 및 문자, 공지된 디자인상 중요도 낮게 평가, 미감이 유사

(2) 용도 유사 - 적극

비밀번호/전화번호 입력기능이 상이, 수치입력용도가 공통되므로, 용도/기능이 유사

III. 설문 3

1. 확대된 선출원주의(法33조3항)

(1) 취지, 의의 및 요건

(2) 부분디자인에서 일부의 특정방법 - 파선 부분 포함 전체에서 상응부분 대비가능표현

2. 화면디자인과 화상디자인 간 유사 판단방법 - 용도/기능 유사 또는 혼용가능성, 형태유사

3. 설문 3의 해결 - D 적용되지 않음

(1) C/D 선/후출원

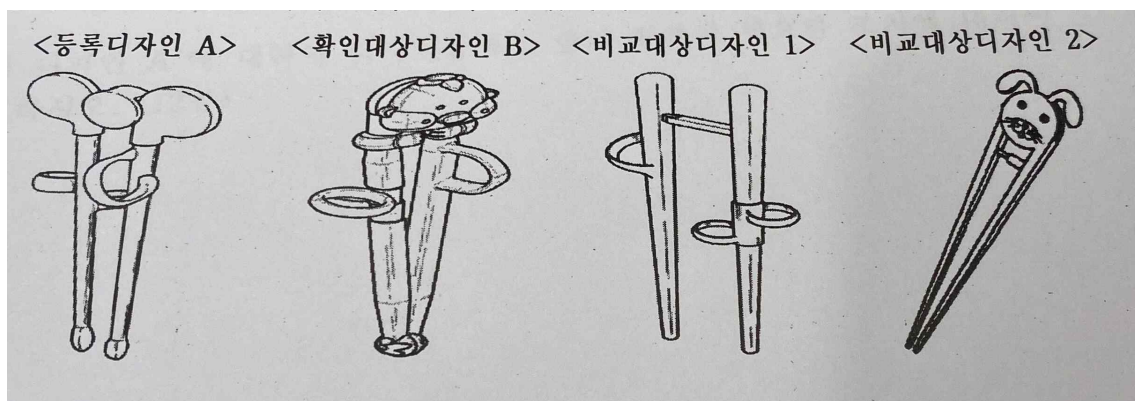
(2) C 디자인공보 게재

(3) C/D 대응되는 부분간 용도/기능이 산업기계조작용/화면잠금해제용으로 상이, 혼용가능성이 없어 비유사

(3) 결론 - D 法33조3항 적용되지 않음

[문제-3] (30점) (관련 판례는 대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후913 판결 [권리범위확인 (디)], 다만 일부 사실관계는 상이함)

甲의 등록디자인 A와 乙의 확인대상디자인 B는 “어린이 젓가락 사용법 교육용 젓가락(물품동일)의 형상과 모양에 관한 디자인”이다. 확인대상디자인 B의 “손가락 삽입부”는 등록디자인 A의 “손가락 삽입부”와 유사한 한편(구성1-공통, 비교1에 공지? 기능적 부분?), 확인대상디자인 B의 “꺾 부분”은(구성2-차이, 비교2에 공지됨) 유명 캐릭터를 부착하고, “젓가락 몸체 하단 부분”(구성3-차이, 기능과 관련, 대체가능함(예시-1))은 음식물을 잘 집게 하기 위하여 손가락 모양의 볼록한 꽃문양으로 이루어졌다. 비교대상디자인 1, 2는 모두 이 사건 등록디자인 출원 전에 공지된 “젓가락의 형상과 모양에 관한 디자인”이다. 다음 물음에 답하시오.



(1) 디자인 성립요건으로서 “심미성”에 대하여 설명하시오. (7점) (2조1호, 34조4호, 흠결시취급, 미/미감에 관한 견해의 대립)

(2) 동일한 물품에 대해 대법원 판례를 중심으로 아래의 기준을 각각 설명하시오. (15점)

1) 디자인 유사 여부(관련법조문은 33, 46, 92) 판단의 관찰방법에 있어서의 구체적 판단기준 (7점) (대비관찰, 전체관찰, 요부관찰)

2) 디자인의 일부에 공지부분(신규성, 중요도를 낮게 평가/포함해서 판단/나머지 대비)이 있는 경우와 디자인 일부에 물품의 기능(34조4호, 기능에불가결한형상은중요도를 낮게평가/선택 가능한대체형상존재)에 관련된 형태가 있는 경우, 유사 여부의 구체적 판단기준 (8점)

(3) 甲이 乙에 대하여 적극적 권리범위확인심판을 제기하였을 경우, 물음 (2)에 따른 결과를 설명하시오. (8점) (물품동일, 디자인유사, 공통점/차이점/평가를 포섭)

I. 설문 1

1. 심미성(法2조1호)
2. 흠결시취급(法33조1항본문)
3. 디자인보호법상 미의 의미
(1) 견해의 대립 - 기능미설/ 장식미설
(2) 法34조4호 및 검토
4. 디자인보호법상 미감의 판단기준
(1) 견해의 대립 - 주의환기설, 취미감설, 심미성설, 미적처리설
(2) 대법원의 태도 - 취미감설(95후1449 판결, 용기뚜껑 사안) / 심사기준 - 미적처리설(3) 검토 - 취미감설

II. 설문 2-1

1. 유사 판단의 대상 - 法93조
2. 전체적 대비관찰에 관한 대법원의 태도 - 구성요소분리개별판단X, 전체적대비관찰O, 보는 사람상이한미감일으키는지 여부로 판단 (QN디자인보호법 10페이지, 2013다202939 참조)
3. 요부관찰에 관한 대법원의 태도 - 지유세차/판단기준 - 물품의성질, 용도, 사용형태 (QN디자인보호법 10페이지, 방호방지대 사안 2011후3727 참조)
4. 요부에 대한 대법원의 태도 - 참신한/잘관찰되기쉬움/차지하는비중이높은부분 (QN디자인보호법 10페이지, 메추리알 포장용기 사안 2012후3794 참조)

III. 설문 2-2

1. 관련 법조문 - 신규성(33조1항각호), 34조4호
2. 디자인의 일부에 공지부분이 있는 경우
(1) 등록요건 판단시 대법원의 태도(2010후2209 아이팩마스크 사안 참조) - 포함 전체관찰
(2) 권리범위 판단시 대법원의 태도(2011후2737 산업용안경 사안 참조) - 독점권 불인정, 중요도 낮게 판단, 나머지 특징부가 비유사하면 권리범위 속하지 않음
3. 디자인의 일부에 기능 관련 형태가 있는 경우
(1) 물품의 기능에 불가결한 형태인 경우 - 중요도 낮게 평가 (2003후1666 밀폐용기 참조)
(2) 대체가능한 형태가 있는 경우 - 중요도 낮게 평가 불가 (2016후1710 화물차량용 공구함 참조)

IV. 설문 3

1. A/B 물품 유사 - 어린이 젓가락 사용법 교육용 젓가락으로 동일
2. A/B의 공통점 - 손가락 삽입부
3. A/B의 차이점 - 캡 부분, 젓가락 몸체 하단 부분
4. 공통점의 중요도 - 낮음
(1) 비교대상디자인 1 에 개시, 기능적 부분으로 중요도 낮게 평가
(심결(1)2008당3118)은 동일한 입장, 다만, 특허법원(2)2009허6670) 및 대법원(3)2010후913)은

1) 양 디자인에서 유사한 손가락 삽입부는 젓가락질 교정용 젓가락으로서 당연히 있어야 할 부분으로 기본적으로 기능적 부분이어서 심미감에 크게 영향을 미치는 부분이 아니라는 점, 또한 이 사건 등록디자인의 출원 전에 비교대상디자인 1, 2에 의하여 공지된 부분이라는 점 등에 비추어 볼 때, 이러한

비교대상디자인1-2에 그대로 나타나 있지 않고 엄지삽입부의 D자형상이 기능확보에 불가결하지 않으므로, 중요도를 낮게 평가할 수 없다는 입장)

5. 차이점의 중요도 - 높음

(1) 캡 부분 - 잘 보이는 부분(대법원 4)2013후913), 비교대상디자인 2에 다른 캐릭터(토끼)와 다른 캐릭터 개시, 요부에 해당

(2) 젓가락 몸체 하단 부분(대법원 5)2013후913) - 1,2에 공지X, 젓가락의 식품을 짚는 기능과 관련된 부분이나, 1/2와 같이 대체가능한 형태가 존재

6. 설문 3의 해결 - 보는 사람으로 하여금 미감이 상이하므로, 비유사, B는 A의 권리범위에 속하지 않음

- 유사점①, ②, ③들은 양 디자인의 유사여부를 판단함에 있어 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다
- 2) 나. 손가락 삽입부가 비교대상디자인 1, 2에 의하여 공지되었는지 여부
- 우선, 위에서 본 바와 같이, 비교대상디자인 1, 2에 의하여 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1, 2의 공통된 부분, 즉 젓가락 몸체에 엄지, 검지, 중지의 삽입부가 형성되고, 특히 한쪽 몸체에는 엄지 삽입부가, 다른 한쪽 몸체에는 검지와 중지의 삽입부가 각각 부착되어 있으며, 검지·중지 삽입부의 형상이 원형의 고리인 점은 공지되었다고 할 것이다.
- 그러나 한편, 손가락 삽입부는 일상생활에서 흔하고 자주 볼 수 있는 젓가락에 독특하게 부가된 부분이라는 점에 비추어 보면, 각 손가락 삽입부의 상대적인 배치와 각도 및 형태는 전체적인 심미감에 중요한 영향을 미치는 부분이라고 할 것인데, 위에서 본 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1, 2의 각 엄지 삽입부 형상의 차이, 엄지 삽입부 및 검지·중지 삽입부의 배치 방향과 평면상 각도의 차이는 디자인의 심미감에 중요한 영향을 줄 수 있는 정도라고 할 것이어서, 이 사건 등록디자인은 위와 같은 차이점으로 인하여 비교대상디자인 1, 2에 비하여 새로운 심미감을 갖는다고 할 것이다.
- 다. 손가락 삽입부가 물품의 기능 확보를 위해 필요한 부분에 불과하여 유사성의 폭을 좁게 보아야 하는지 여부
- 손가락 삽입부에 의하여 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 대상 물품이 특히 어린이에게 젓가락 사용법을 교육시키거나 젓가락질이 미숙한 사람이 젓가락 사용법을 교정하기 위한 용도 등으로 사용될 수 있다고 할 것이므로 손가락 삽입부가 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 대상 물품의 기능 확보를 위해 필요한 부분이라고 볼 수는 있지만, 나아가 이 사건 등록디자인의 손가락 삽입부가 그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이 존재하지 않는지에 관하여 보건대, 젓가락 사용법 교육용 혹은 교정용으로 손가락 삽입부가 부착된 젓가락은 일반적으로 젓가락을 사용하는 데 사용되는 엄지와 검지 및 중지가 각각 삽입될 수 있는 삽입부가 젓가락 몸체에 부착되고, 특히 한쪽 몸체에는 엄지 삽입부가, 다른 한쪽 몸체에는 검지와 중지의 삽입부가 각각 부착되며, 각 삽입부의 형상과 크기가 각 손가락이 삽입될 수 있을 정도의 형상과 크기를 구비하면 그 기능을 다하는 것이므로, 이러한 기능을 다하기 위해서 반드시 엄지 삽입부의 형상이 D 자와 유사한 형태의 고리이어야 하고, 엄지 삽입부 및 검지·중지 삽입부의 평면상 각도와 검지·중지 삽입부 상호간의 평면상 각도가 각각 약 90 도를 이루고 있어야 한다고는 볼 수 없고, 동일한 기능을 수행하면서도 전체적인 미감을 고려하여 각 손가락 삽입부의 상대적인 배치와 각도 및 형태는 얼마든지 다르게 구성될 수 있다고 봄이 상당하다.
- 3) 젓가락 몸체에 형성된 손가락 삽입부의 배치 위치와 방향 및 형상, 평면에서 본 각도 등에서 유사하고, 위와 같은 손가락 삽입부의 유사점은 그것이 원심판시 비교대상디자인들에 그대로 나타나 있거나 나 물품의 기능 확보를 위하여 필요한 부분에 불과하다고 볼 수 없어 그 중요도를 낮게 평가할 수는 없다.
- 4) 그러나 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 캡 부분은 젓가락에서 흔히 있는 형상이 아니고 수요자에게도 잘 보이는 부분이어서 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분으로 양 디자인의 요부 중 하나에 해당한다 할 것인데, 캡 부분의 형상이 이 사건 등록디자인은 ‘ ’과 같이 콩나물 머리모양의 캡이 대칭을 이루고 그 사이에 원형의 연결부재가 설치된 형상인 반면, 확인대상디자인은 ‘ ’과 같이 ‘방귀대장 뽕뽕이’ 캐릭터의 얼굴과 그 아래에 손으로 젓가락 몸체를 감아쥔 형상인 점에서 현저한 차이가 있고,
- 5) 그 밖에 몸체 끝부분이 이 사건 등록디자인은 ‘ ’과 같이 뭉툭하게 되어 있는 형상인 반면, 확인대상디자인은 ‘ ’과 같이 손가락 형상으로 그 볼록면에 꽃문양이 형성되어 있는 점 등에서도 차이가 있으며, 이러한 형상의 차이는 전체적인 심미감에 큰 차이를 가져올 정도이다.

[문제-4] (20점)

甲은 스마트워치(10류, 심사등록물품)에 관하여 신규한 디자인 A를 창작하여 (선출원)2021. 6. 1. 디자인등록출원하였으나 거절결정되어 확정(선출원 소멸, 공개/비공개)되었다. 그 후 乙은 甲의 디자인과 동일한 (후출원1)디자인 A와 이와 (후출원2, 동일인간 선출원주의, 관련디자인) 유사한 디자인 A'을 창작한 후, 이들 각각에 대하여 2022. 7. 1. 디자인등록출원하였다(도면에 2이상의 디자인이 도시되어 있는지 불명확하나 배점상 검토). 다음 물음에 답하시오.

(1) 乙(타인)의 디자인 A는 등록받을 수 있는지 여부에 대하여 설명하시오. (단, 이때 디자인 A'은 고려하지 않음) (8점)(주논점-선출원소멸, 심사등록물품을 간단히 포섭)

(2) 乙이 디자인 A'에 대하여 디자인등록을 받기 위하여 필요한 조치에 대하여 설명하시오.(여기서는 디자인 A'를 고려함, 주논점-선출원주의, 관련디자인X 관련디자인O/조치1) 관련디자인보정, 조치2) A'를 선택, A를 취하, 부논점-1디자인(복수디자인), 조치0) 보정/분할) (12점)

I. 설문 1

1. 선출원주의(法46조1항)

(1) 취지, 의의 및 요건

(2) 위반시 취급 - 거절이유(法62)

2. 거절결정 확정시 선출원의 지위가 소멸되는지 - 적극

(1) 구법상 문제점 - 유사역 연쇄거절

(2) 07.7.1 시행 개정법상 타당성 - (法46조3항) 선의의 제3자의 창작을 보호

3. 설문 1의 해결

(1) 전제 - 스마트워치는 심사등록물품

(2) 甲 A 출원(21.6.1) 과 乙 A 출원(22.7.1) 동일

(3) 다만, 甲 A 출원(21.6.1) 거절결정 확정시 소급소멸, A는 등록받을 수 있음

II. 설문 2

1. 동일인/동일자간 선출원주의 위반 여부 - 적극

(1) 法46조2항상 위반

(2) 法35조1항상 동일인간에도 적용

2. 관련디자인등록출원의 적법성 (法35조)

(1) 취지, 의의 및 요건

(2) 효과(法35조1항) - 자기의 기본디자인과의 관계에서 法46 극복가능

3. 1디자인 및 복수디자인등록출원의 적법성

(1) 法40조1항 취지, 의의 및 요건

(2) 위반시 취급 - 거절이유(法62)

(3) 극복방법 - 삭제보정/분할출원(法48,50)

(4) 法41조 요건 및 효과- 1디자인의 예외, 일체성배제

4. 설문 2의 해결 - 法46조2항에 대한 乙의 조치

(1) 法 46조 5항 - A'의 선택 결과를 지정기간 내 신고

(2) 法 46조 4항 - 출원 취하

(3) A' 관련디자인등록출원 또는 보정(法48조2항)

1) 22.7.1~1년 내 A-A' 유사, 甲 A 소멸, 기본디자인/관련디자인 취지 기재, 전용실시권/관련 디자인과만 유사한 사정 없어 적법

5. 설문 2의 해결 - 法40조1항에 대한 乙의 조치

(1) A-A' 복수디자인등록출원 - 2개, 동일한 물품, 일련번호별로 도시한 경우 적법

(2) A-A'를 1출원한 경우 - 보정/분할출원